

1500317-17.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500317-17.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000127

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2032278/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO ANTONIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

GUSTAVO ANTÔNIO DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, trazia consigo e tinha em depósito, em sua residência, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, grande quantidade de entorpecente, para fins de tráfico, a saber:

- 977,500g de substância METIL BENZOIL ECGONINA, comumente conhecida como cocaína, substância em pó esbranquiçada, acondicionada em 1 invólucro plástico transparente, lacrado por nó. Misturada à substância supracitada, foi detectada a presença de cafeína;

- 290,460g de substância METIL BENZOIL ECGONINA, comumente conhecida como cocaína, substância em pó esbranquiçada, acondicionados em 940 invólucros plásticos de cor verde, do tipo eppendorf;

- Além do exposto, foram encontrados e apreendidos os seguintes petrechos:

- 56 MICROTUBOS COR VERDE;

- 1 PENEIRA;

- 1 BALANÇA METÁLICA, tipo de medidores/instrumentos de precisão.

Narra a denúncia que notícia feita ao COPOM relatava que no local da ocorrência havia chegado grande quantidade de drogas e que estas estavam sendo embaladas. Diante disso, os policiais militares deslocaram-se até o local dos fatos. Ao chegarem ao endereço informado, avistaram, por meio da janela existente para a Rua Tabatinga, o acusado separando as drogas, ao mesmo tempo em que este também os viu e então colocou tudo em uma sacola plástica e saiu correndo para os fundos. Diante disso, os policiais militares invadiram a residência e viram, de modo nítido, o acusado arremessando a sacola no telhado do imóvel.

O acusado foi abordado. Na sacola plástica arremessada no telhado, foram encontradas novecentas e trinta cápsulas contendo cocaína, um quilo a granel de cocaína. Promovida busca no imóvel, foram localizados, no quarto do acusado, uma balança, uma peneira, cinquenta e seis cápsulas vazias e mais dez cápsulas contendo cocaína. Quando indagado, o acusado alegou ter preenchido os pinos com drogas a fim de entregá-los em Serrana/SP.

Apresentado na audiência de custódia em 04 de fevereiro de 2022, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 50/52).

Pessoalmente notificado (pág. 88), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 103/105) e a denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 07 de abril de 2022, na mesma oportunidade em que indeferida a revogação da prisão preventiva do acusado (págs. 112/115), promovida, em seguida, sua citação (pág. 147).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado (pág. 190). Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa (págs. 197/220) arguiu, em preliminares, nulidade das provas em decorrência da violação de domicílio no período noturno, sob a falta de demonstração de fundadas razões para a invasão policial, seja por ser inidônea a tanto denúncia anônima desacompanhada de investigações preliminares, seja porque, diante das circunstâncias do imóvel, os policiais não seriam capazes de, por meio da elevada janela do nível da rua, enxergarem o acusado no quarto separando as drogas e correndo para os fundos; sobre o assunto, reputou contrariados o tema 280 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e o HC nº 598.051/SP do Superior Tribunal de Justiça, bem como listou julgados deste Tribunal de Justiça Paulista. Ainda em caráter preliminar, reputou quebrada a cadeia de custódia, com violação, portanto, ao artigo 158-A, do Código de Processo Penal, na elaboração do laudo de constatação de págs. 18/21 e do exame químico definitivo de págs. 65/68, segundo apontamentos aos quais fez menção do Parecer Técnico nº 65/22, juntado às págs. 169/182, confeccionado por perito particular e, em reforço, trouxe de referência sentença prolatada pelo foro de Campinas.

No mérito, argumentou ausência de dolo e erro de tipo, eis que acusado não tinha ciência de que a substância a ele entregue por terceira pessoa consistiria em entorpecente.

Subsidiariamente, na dosimetria, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da confissão como circunstância atenuante, com a imposição de regime prisional aberto, além do direito de o acusado apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

Dener de Paula Lima Júnior, policial militar, recordou que a equipe recebeu denúncia anônima via COPOM com a notícia de haver chegado grande quantidade de drogas em dado imóvel e que o rapaz fazia o embalo para distribuição, razão pela qual, após diligências no período entre às 18h e 20h, no local apontado, com janela aberta que dava visão para rua, por meio do qual, pelo próprio ângulo da rua, visualizaram o acusado no quarto manipulando os entorpecentes, quando então, ao notar a presença da viatura, recolheu a sacola que continha, nitidamente, eppendorfs e saiu às pressas para o interior da casa.

Expôs o policial Dener que o portão de grade do lado esquerdo da janela estava aberto e, na entrada, ele e seus companheiros de farda viram o acusado no quintal

arremessando a sacola para cima do telhado (nela também havia quantidade de cocaína a granel), quando então, uma vez abordado, admitiu preencher os “pinos” durante o dia para depois levar para venda nas “biqueiras” de outra cidade, sendo que mais uns outros dez eppendorfs, além daqueles do telhado, devido à furtividade naquele primeiro instante à agilidade em pegar a sacola, foram encontrados naquele mesmo quarto avistado no começo; destacou que no momento da diligência não havia ninguém além do acusado dentro do imóvel.

Laerte Júnior Araújo de Souza, também policial militar, a par das informações prestadas por seu companheiro de corporação acima citado, reforçou que a denúncia anônima especificava o endereço e ser pessoa do gênero masculino que guardava droga; da janela aberta a equipe policial teve prontas condições de visualizar (disse ter 1,70m de altura e ser de fácil acesso visual o cômodo) o acusado em cima da cama manipulando os entorpecentes e, percebida a presença policial, as drogas que mais rapidamente conseguiu colocar na sacola assim o fez e saiu rumo ao interior do imóvel.

Como o portão lateral estava aberto, continuou o policial Laerte, a equipe ingressou e o acusado correu para os fundos, de onde arremessou a sacola para cima do telhado, sobre a qual, ao ser indagado, confirmou ser droga, daí então retornaram para o quarto e em cima da cama foram encontradas aproximadamente dez cápsulas de eppendorfs cheias, mais outras cinquenta vazias, uma balança de precisão e uma peneira.

O Policial Laerte seguiu a relatar ter o acusado dito que embalou a droga e ia fazer entrega na cidade de Serrana; refutou a existência de outra pessoa dentro do imóvel a não ser o próprio acusado e, diante da movimentação de viaturas, o filho que brincava pela rua, junto de outras crianças, chegou a comparecer no local, além de algumas mulheres com as quais fez contato para familiares serem avisados sobre a ocorrência.

Fernanda Pereira de Andrade disse ser conhecida de Maiara, esposa do acusado, do qual é vizinha (mora na rua Tabatinga, nº 875) há mais de um ano; o casal tem dois filhos menores; declinou que o acusado, junto do primo, trabalha de entregador no Mercado Livre e a esposa, numa casa de família durante o dia; desconhece fatos desabonadores ou de envolvimento do acusado com drogas.

Fabiana Carla Muniz Neves declarou morar na rua Tabatinga, nº 887, vizinha do acusado, conhecido seu há aproximadamente um ano, sobre o qual, por informações da esposa dele, soube trabalhar de entregador no Mercado Livre; negou ter ouvido qualquer comentário na vizinhança de o acusado ser envolvido com drogas.

Interrogado, o acusado alegou estar com aluguel atrasado, com dois filhos menores para cuidar, sem emprego, e conhecido seu lhe propôs de guardar uma sacola contendo produtos de “mistura”, balança, cápsulas e peneira, em troca de oitocentos reais, tendo aceitado por força das dificuldades financeiras enfrentadas; continuou a declarar que no dia seguinte, às 17h, tal conhecido seu pediu que enviasse a localização via whatsapp, quando então o atendeu em casa e dele pegou uma sacola preta que foi, em seguida, colocada em cima da estante da sala (meia hora depois teve a transferência via PIX para sua conta do valor prometido de oitocentos reais), sendo que, no mesmo dia, estando na presença de seus dois filhos, olhou para a varanda e viu um policial parado em pé, já dentro (ao qual não deu nenhuma autorização para ali ingressar), o que despertou medo, razão pela qual pegou a sacola, correu para o fundo e jogou para cima do telhado.

Nesse contexto, explicou o acusado, o policial o viu lançando a sacola, foi abordado e preso; informou que ao receber a primeira visita de sua esposa no CDP, teve informações dela de que, passados três dias dos fatos, ao chegar do trabalho, deparou-se com um rapaz na porta da casa à espera, o mesmo rapaz de quem recebeu a sacola, o qual jurou a ela que na sacola não havia drogas, mas apenas “produtos para misturar” e que iria contratar advogado para prestar apoio.

Complementou ter tatuagens nas costas, o nome de sua família no peito e mais outra no pulso direito; disse ajudar seu sobrinho, dia sim, dia não, na entrega de produtos do Mercado Livre, para cuja função recebia em torno de um mil e duzentos reais mensais; fez menção de a janela de sua casa ser alta em relação ao nível da rua e, sobretudo naquele horário da diligência policial, tem o hábito de deixá-la

fechada, por motivos de segurança e para proteger seus filhos.

Preliminar – Prova ilícita decorrente da busca domiciliar sem mandado

A pretensa nulidade decorrente da suposta violação de domicílio não encontra amparo no acervo de provas reunidos, sobretudo porque os policiais, tanto Dener como Laerte, desde o início (págs. 2/4), o que constou no BOPM (págs. 130/133), como também em juízo, frisaram que, para apurar a denúncia anônima daquela data, compareceram no local indicado e do próprio ângulo da rua, através da janela, avistaram o acusado em cima da cama manuseando entorpecentes colocando-os na sacola e não apenas por essa circunstância, como também pela atitude de fuga tomada para dentro do imóvel, é que mais ainda se confirmou aquilo que havia motivado a diligência até o local.

É de se observar que o acusado admitiu em juízo ter atendido o dito rapaz que ali chegou numa moto, em cuja ocasião a sacola preta foi recebida, às 17h e, depois de se deparar com o policial já dentro da casa, realmente fugiu pelo quintal e arremessou a sacola para o telhado.

As circunstâncias gerais são praticamente todas compatíveis ao que veio relatado em juízo pelos policiais, exceto pela parte que busca acrescentar elementos de cena não congruentes ao acervo de provas, ao pretender afirmar que a mesma janela encontrava-se fechada e deparou-se, de surpresa, com o policial já no interior de sua varanda.

A desfazer essa probabilidade elisiva de responsabilidade, cabe confrontar a denúncia anônima em toda sua extensão fornecida pelo centro de operações da polícia militar (transcrição trazida aos autos classificada como peças sigilosas), a partir da qual se colhem dados contundentemente precisos, tanto do local, circunstâncias de recepção dos entorpecentes e nome do Gustavo como a pessoa envolvido no exercício do tráfico.

ATENDENTE: Tabatinga 855 (oito cinco cinco)?

USUÁRIO: É, com avanhandava, a casa dele é uma casa verde, do muro verde, aqui de de esquina.

[...]

ATENDENTE: o QUE O SENHOR VIU, DE QUE, COM TABLETE?

USUÁRIO: É, tablete, porque veio um rapaz de moto aqui, ele mexeu lá no no nos caco lá, e “cato” 2 (dois) tablete (trecho ininteligível) entregando “pro” rapaz i é direto isso.

[...]

ATENDENTE: É um saco um saco de lixo cor preta é isso?

USUÁRIO: É tipo um saco de batata sabe?

[...]

ATENDENTE: “Tá” “cê” consegue me passar alguma característica dele?

USUÁRIO: Ele é branco, meio gordo, com uma tatuagem nas costas.

[...]

ATENDENTE: “Tá” certo, ó “tá” cadastrada a solicitação, só aguardar o atendimento, o nome “desse” indivíduo você sabe ou não?

USUÁRIO: É Gustavo.

ATENDENTE: Gustavo?

USUÁRIO: É a “muié” dele chama ele de “gu”, é Gustavo, os “povo” chama ele de “gu” Gustavo.

A completa descrição fornecida via 190 e transmitida à equipe que atendeu à ocorrência teve fundadas razões de confirmação ao ser o acusado visto, pela janela, manipulando os entorpecentes, contexto idôneo a reputar o acusado em estado de flagrante.

Mesmo que tomado em parâmetro o precedente STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Informativo 687), o relator teria proposto a fixação do prazo de um ano para o aparelhamento dos órgãos de segurança pública na captação das operações/diligências por áudio e vídeo, mas se trata de providência que, mais adiante, foi revista e anulada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo principais trechos trazidos abaixo extraídos do voto condutor do Ministro

Alexandre de Moraes, no RE 1342077, Julgamento: 02/12/2021, Publicação: 06/12/2021: "Ocorre, entretanto, que a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, não só transformando o presente habeas corpus individual em um habeas corpus coletivo, como também estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes e determinando em abstrato e com efeitos vinculantes e erga omnes a todos os órgãos da administração de segurança pública do País – estaduais, distrital e federal – verdadeira obrigação de fazer inexistente na Constituição Federal e na legislação [...]

Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Superior Tribunal de Justiça, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

A decisão, portanto, não merece prosperar"

Reputa-se hígida, portanto, a diligência, também se o enfoque for projetado para o tema 280 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do qual se estabeleceu a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

Na hipótese ora enfrentada, as fundadas razões emergiram nítidas na sucessão de eventos a começar da denúncia anônima pormenorizada e no, enfim, encontro do acusado, pela vista possibilitada pela janela, manipulando a mesma sacola preta indicada na ligação comunicada via 190, tudo a consolidar fundamentos mais que verossímeis e persuasivos ao ingresso dos policiais na residência e coibir o crime em curso.

Ainda a isso é necessário acrescentar que o crime em debate enquadra-se como de natureza permanente, em função da qual, somado a todos os elementos trazidos, torna dispensável a expedição de mandado de busca domiciliar, a exemplo dos arestos do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionados:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE ILEGALIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME PERMANENTE. FORTE ODOR DE MACONHA. NERVOSISMO DO PACIENTE. RAZÃO PARA REALIZAR A BUSCA NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE 667 PORÇÕES DE CRACK (286,14 G), 1.605 INVÓLUCROS DE MACONHA (6.731,81 G), 1.244 INVÓLUCROS DE COCAÍNA (1.533,23 G) E 35 FRASCOS DE LANÇA-PERFUME. 1. Consta nos autos que os policiais perceberam o nervosismo do paciente e que ao chegarem à residência, já sentiram um forte odor de maconha, razão pela qual fizeram a busca dentro da residência. 2. Agravo regimental improvido." (STJ; AgRg no HABEAS CORPUS Nº 423.838 - SP (2017/0288916-6); Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; Julgamento: 08/02/2018; Publicação: 19/02/2018).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...] 5. Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no RESp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017).

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. OFENSA AO ART. 240, § 1º, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU

AUTORIZAÇÃO. (ART. 5º, XI, CF). DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. OFENSA À PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 44, I, CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF. [...] 8. Habeas corpus não conhecido." (STJ; HC nº 352.811/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Publicação 1º/8/2016).

Os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJ-SP; APL 0000044-47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120); "Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção." (TJ-SP; APL 00000750-41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743); "Os depoimentos dos policiais que efeturaram a prisão em flagrante são perfeitamente válidos como prova. Os atos praticados pelos policiais, além de dotados de fé pública e possuírem presunção iuris tantum de veracidade, retratam as circunstâncias da prisão. Tais depoimentos somente não seriam válidos se ficasse demonstrado algum interesse pessoal ou qualquer arbitrariedade que pudesse comprometer a veracidade deles, o que não se verificou no caso concreto (Precedentes do STJ; STF; e desta Corte)" (TRF 02ª R.; ACr 0807483-30.2010.4.02.5101; Primeira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Abel Gomes; Julg. 28/06/2017; DEJF 14/07/2017).

Preliminar – quebra da cadeia de custódia dos laudos periciais
As arguições envolvendo a quebra da cadeia de custódia estão lastreadas em seis fundamentos, em síntese: I) consistentes na diferença entre a quantidade de material apreendido e o efetivamente pesado; II) o perito não consignou o tipo de ensaio e método utilizado, sequer registrando fotograficamente as reações; III) o restante dos materiais A1 e A2 foram colocados na mesma embalagem com lacre nº 7589571, apesar de o material A1 ter resultado negativo para cocaína, enquanto o material A2 resultado positivo; IV) o exame químico toxicológico definitivo guarda

divergência com o laudo de constatação, pois neste a amostra A1 resultou negativa e no outro positiva para cocaína; V) o exame químico toxicológico não faz menção a amostra de padrão de referência, ou seja, não comparou o perfil cromatográfico e coloração da mancha do material analisado com o obtido com o material de referência; e VI) no exame químico toxicológico definitivo parte dos materiais conservados para contraprova não foi lacrada como forma de garantir a autenticidade e confiabilidade das amostras.

Os materiais apreendidos e coletados na residência do acusado foram com minúcias listados, um a um, no auto de exibição/apreensão de págs. 14/15 e, com especial recorte aos entorpecentes, assim se consignou:

Pessoa Relacionada GUSTAVO ANTONIO DA SILVA, Tipo de Tóxico Cocaína, Quantidade 1000,5 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 1, Observação LACRE: 019366

Tipo de Tóxico Cocaína, Quantidade 1004,3 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 940, Observação LACRE: 019373

As requisições expedidas pela autoridade policial (pág. 17) ao Núcleo de Criminalística guardam aderência aos objetos e contém a numeração de lacres que foram submetidos à análise técnica, correspondentes aos mesmos declinados no auto de exibição/apreensão.

Seguindo adiante, o exame químico toxicológico de constatação (págs. 18/21) anotou como recebidos e analisados:

Acondicionados em saco plástico transparente, lacrado sob nº 019366:

A1) 01 (um) invólucro plástico incolor, vedado por nó, contendo substância em pó esbranquiçada. Totalizou-se massa líquida de 977,500g (novecentos e setenta e sete gramas e quinhentos miligramas).

IMPORTANTE

Parte do material (A1) foi consumido nas análises e outra parte conservada para eventual contraprova, totalizando 2,000g (dois gramas), sendo o restante do material, 975,500 (novecentos e setenta e cinco gramas e quinhentos miligramas), e as respectivas embalagens, devidamente acondicionados, identificados e inseridos em invólucro plástico transparente, lacrado sob o nº 7589571 [...]

[...]

Acondicionados em saco plástico transparente, lacrado sob nº 019373:

A2) 940 (novecentos e quarenta) invólucros plásticos de cor verde, do tipo 'eppendorf', capacidade de 1,0 mL, contendo substância em pó esbranquiçada.

Totalizou-se massa líquida de 290,460g (duzentos e noventa gramas e quatrocentos e sessenta miligramas).

IMPORTANTE

Parte do material (A2) foi consumido nas análises e outra parte conservada para eventual contraprova, totalizando 3,090g (três gramas e noventa miligramas), sendo o restante do material, 287,370g (duzentos e oitenta e sete gramas e trezentos e setenta miligramas), e as respectivas embalagens, devidamente acondicionados, identificados e inseridos em invólucro plástico transparente, lacrado sob o nº 7589571.

CONCLUSÃO

A1)

O exame do material acima descrito, submetido à metodologia descrita abaixo, resultou em NEGATIVO para a substância COCAÍNA.

A2)

O exame do material acima descrito, submetido à metodologia descrita abaixo, resultou em POSITIVO para a substância COCAÍNA.

METODOLOGIAS

A)

- Análise de Cocaína e anestésicos locais:

a) Método químico:

a.1) Teste de Scott Modificado e Teste de Solubilidade em ácido.

[...]

E, enfim, no exame químico toxicológico definitivo (págs. 65/68) as informações que nele se vislumbram são:

DOS MATERIAIS

Foi examinado o seguinte material, PREVIAMENTE ABERTO E RESERVADO PARA ANÁLISE DESTE EXAME DEFINITIVO, CONFORME EXARADO NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA - PROTOCOLO Nº 2214566:

A1) 2,000g (dois gramas) de substância em pó esbranquiçada.

A2) 3,090g (três gramas e noventa miligramas) de substância em pó esbranquiçada.

[...]

CONCLUSÃO:

A1)

No material acima descrito, submetido à metodologia descrita abaixo, foi DETECTADA a presença da substância METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) [...]

No material acima descrito, submetido à metodologia descrita abaixo, foi DETECTADA a presença CAFEÍNA [...]

[...]

A2)

No material acima descrito, submetido à metodologia descrita abaixo, foi DETECTADA a presença da substância METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) [...]

[...]

METODOLOGIA:

A)

- Análise Cocaína e anestésicos locais:

a) Método químico:

a.1) Teste de Scott Modificado e Teste de Solubilidade em ácido.

b) Método físico-químico:

b.1) Cromatografia em camada delgada;

b.2) Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas.

Em atenção aos destaques acima promovidos dos conteúdos extraídos de cada situação de movimentação e manipulação dos entorpecentes apreendidos, nota-se inexistir inconsistências de lacres, porquanto o material da amostra A1, oriundo originalmente do lacre nº 019366 registrado no auto de exibição e apreensão, após ser parcialmente consumido no exame provisório, teve a quantidade de 2,000g conservada para contraprova que seguiu armazenada sob o lacre nº 7589571, ao passo que o material da amostra A2, originalmente proveniente do lacre nº 019373 registrado no auto de exibição e apreensão, teve, depois de também ser parcialmente consumido no exame provisório, a parte de 3,090g conservada para contraprova armazenada sob o lacre nº 7589571.

Confere-se, ainda, que o exame de constatação provisória assinala como medição a massa líquida de cada um dos entorpecentes e o exame químico toxicológico tem a diferença de submeter os entorpecentes apreendidos a testes complementares, não apenas ao "Teste de Scott Modificado e Teste de Solubilidade em ácido", como também ao "b) Método físico-químico: b.1) Cromatografia em camada delgada; b.2) Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas".

Diante do contexto apresentado, não se depara com a quebra da cadeia de custódia aventada, já que os entorpecentes seguiram cronologia de armazenamento e manipulação historicamente documentados e preservados nos autos, merecendo colação a elucidativa síntese trazida em acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

"Quebra da cadeia de custódia da prova. Consequências para o processo penal.

Princípio da mesmidade. Necessidade de o magistrado sopesar todos os elementos produzidos na instrução.

(...)

Respeitando aqueles que defendem a tese de que a violação da cadeia de custódia implica, de plano e por si só, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova, de modo a atrair as regras de exclusão da prova ilícita, parece ser mais adequada aquela posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável."

(STJ, HC 653.515-RJ, Rel.Min. Laurita Vaz, Rel.Acd. Min.Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 23/11/2021).

Tais constatações acima referidas são suficientes a se conceber como preservada a cadeia de custódia das provas.

Deve aqui ser lembrado “considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte” (artigo 158-A, do Código de Processo Penal).

Significa dizer que eventuais impugnações aos métodos periciais empregados a se alcançar o resultado positivo para cocaína ou não para o entorpecente examinado não cabem dentro do debate da cadeia de custódia, na medida em que o tema somente se ocupa da situação relacionado ao princípio da mesmidade, isto é, que a prova examinada seja exatamente aquela que foi colhida.

Dissensos que suplantam essa dimensão de historicidade de armazenamento dos elementos de prova devem ser conduzidos à sede própria da fase de instrução, com o requerimento de eventual produção de prova pericial pelo juízo, oportunidade em que, nos termos do artigo 159, do Código de Processo Penal, cada uma das partes tem a faculdade de formular quesitos e indicar de assistentes técnicos, possibilitando eventualmente a transcendência do debate para limites que a cadeia de custódia não comporta.

Mérito – Tráfico de drogas

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 18/21 e no exame químico-toxicológico acostados a págs. 65/68 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal “Erythroxylum coca”, distribuída na massa líquida de 977,500g, acondicionada em 01 invólucro plástico incolor, vedado pro nó, e na massa líquida de 290,460g, armazenada em 940 invólucros plásticos de cor verde, do tipo “eppendorf”, capacidade de 1,0 mL, além de 56 microtubos de cor verde, 1 peneira e 1 balança, conforme auto de exibição/apreensão de págs. 14/15 e laudo pericial de págs. 69/70.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Ambos os militares inquiridos prestaram relatos uníssomos e convergentes no sentido de que, em averiguação da denúncia anônima, cuja transcrição consta como peça sigilosa nos autos e já se teve a oportunidade de abordar seus trechos no tópico acima destinado à preliminar de violação de domicílio, compareceram até o exato local indicado e, através da janela ilustrada a pág. 201, conseguiram acesso visual ao quarto onde o acusado manuseava os entorpecentes e dali fez súbita saída, na posse da sacola, rumo ao quintal, ambiente no qual, conforme por ele mesmo confirmado em interrogatório, foi visto arremessando a sacola no telhado.

O caso concreto não há de ser compreendido como hipótese de ausência de dolo ou de erro de tipo, na medida em que o acusado, ao ser interrogado, deu detalhes que não condizem, por mais pueril que se admita, com situação de imprevisibilidade do conteúdo da sacola, já que elencou ter recebido não só ela, como também a peneira e a balança de precisão, instrumentos que não se mostram afetos a produtos de “mistura”, tudo para fins de mero depósito, em troca de oitocentos reais.

E imaginando tratar-se de sacola contendo apenas “mistura”, mesmo assim ao avistar o policial entendeu por sair em fuga e arremessar a mesma sacola para cima do telhado.

Ocorre que nenhum elemento, sequer indiciário, foi trazido aos autos a amparar tal versão, o que poderia ser facilmente resolvido, seja com as breves conversas trocadas por mensagem com a suposta pessoa que forneceu a sacola e demais materiais apreendidos, seja com o extrato bancário que indicado a percepção da transferência de valores por meio de PIX; a bem da verdade, mesmo comprovada a existência e envolvimento da terceira pessoa no fornecimento da sacola, ainda assim a vinculação imediata do acusado com os entorpecentes encontrar-se-ia estampada nas circunstâncias gerais que conduziram tanto à aparição da equipe policial no local, como em seu comportamento que logo dali foi notado.

Não se pode olvidar que os policiais, em especial Laerte, forneceram a informação de que, uma vez indagado, o acusado admitiu fazer o embalo da droga e pretendia fazer a distribuição na cidade de Serrana, o que se coaduna com o conjunto de apreensões abrangendo tanto a sacola como os demais itens encontrados no quarto. Acrescente-se, para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792); "No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); "Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, variedade, natureza e forma de acondicionamento, divididos em porções individuais, pela detalhada informação apócrifa, cuja veracidade foi constatada pelos agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas, quanto ao destino a terceiros, salientando-se que eventual condição de usuária não seria impeditiva da realização concomitante do comércio clandestino, o que arreda a tese desclassificatória ventilada em autodefesa." (TJ-SP; APL 0001364-89.2016.8.26.0537; Ac. 10947155; São Bernardo do Campo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2794).

Destarte, os elementos reunidos em todo o percurso da instrução probatória confirmam que a destinação dos entorpecentes seria para terceiras pessoas, pois em condições próprias a tanto de armazenamento, de embalagem, fracionamento, tudo em ambiente, segundo asseverado pelos policiais, guarnecido por outras ferramentas típicas ao exercício do tráfico, como a balança de precisão e a peneira.

Desta forma, caracterizado o crime de tráfico de drogas, passo à dosagem da pena: I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável o mau antecedente (Processo nº 0003472-84.2011.8.26.0596 - 1ª Vara de Serrana, pág. 40, com término da execução 1 em 24/10/2016, págs. 47/48), a majorar a pena em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa;

Para esta vetorial, relevante consignar que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tese fixada no julgamento do Tema 150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal), além do que a Corte igualmente entendeu como incompatível ao ordenamento jurídico brasileiro o denominado direito ao esquecimento, no julgamento do RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Tema 786 da repercussão geral divulgado no informativo de jurisprudência 1005).

Outrossim, desfavoráveis as consequências do crime, ante a expressiva quantidade de droga, detidamente listada no auto de exibição/apreensão (págs. 14/15), no laudo de

constatação provisória (págs. 18/21) e no exame químico-toxicológico (págs. 65/68), com o encontro de mais de um quilo de cocaína a granel, além das cápsulas já preenchidas, circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição da droga. Nesse sentido: “1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 2 anos de reclusão com fundamento na natureza, na variedade e na quantidade dos entorpecentes apreendidos - 1 porção de crack (988,41g) e 4 porções de cocaína (1.543,03g) -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), e a preponderância de tais circunstâncias conforme estabelece o art. 42 da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 553.106/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 19/05/2020), justificando o aumento de um ano de reclusão e cem dias-multa.

Relembra a variação da pena de cinco a quinze anos, cumpre fixar a pena-base em seis anos e seis meses de reclusão e pagamento de seiscientos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a reincidência (Processo nº 0005353-09.2005.8.26.0596 - 1ª Vara de Serrana/SP, trânsito em julgado p/ defesa em 23/04/2013, págs. 40/41, em cumprimento da execução 2, pág. 48), a importar o aumento de um ano de reclusão e cem dias-multa, perfazendo o subtotal da pena de sete anos e seis meses de reclusão e pagamento de setecentos e cinquenta dias-multa;

Não é caso de ser acolhida a pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão, já que, segundo a Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”, tendo o acusado refutado o conhecimento de estar armazenando drogas em depósito, tampouco admitido o exercício do tráfico; III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressalvando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, porque portador de mau antecedente em tráfico de drogas e reincidente, conforme anotado nos itens “I” e “II” acima. Torno definitivo o quantum de sete anos e seis meses de reclusão e setecentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e a hediondez preservada ao caput da capitulação sob a qual incurso o acusado, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento. Insuficiente o critério objetivo temporal para progressão para o regime semiaberto (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal), iniciará o cumprimento no regime original.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência condeno GUSTAVO ANTÔNIO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de sete anos e seis meses de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de setecentos e cinquenta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas (mantido o indeferimento da gratuidade da justiça deliberado no item “V” de pág. 114).

Em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 50/52), sobretudo agora por estar emoldurada a condenação ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ou seja, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal,

porquanto com o elevado montante da pena e regime prisional imposto a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recursos, extraia-se guia de execução provisória.

Comunique-se à autoridade policial a autorização para, a depender do estado de conservação, e porque inservíveis e inexpressivos economicamente, providenciar, se o caso, a destruição dos microtubos, da peneira e da balança de precisão listados no auto de exibição/apreensão de págs. 14/15.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Ribeirão Preto, 7 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA